



Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

RESOLUCIÓN N° 000378-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA

Expediente : 00194-2023-JUS/TTAIP
Recurrente : **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA**
Entidad : **COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS**
Sumilla : Declara fundado recurso de apelación

Miraflores, 2 de febrero de 2023

VISTO el Expediente de Apelación N° 00194-2023-JUS/TTAIP de fecha 23 de enero de 2023, interpuesto por **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA** contra la respuesta contenida en el Oficio N° 152-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023, a través del cual el **COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS** denegó la solicitud de acceso a la información pública reencauzada mediante el OFICIO N° 00648-2022-MINDEF/SG-OAIP¹ de fecha 27 de diciembre de 2022.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Mediante el OFICIO N° 00648-2022-MINDEF/SG-OAIP, recepcionado por la entidad con fecha 28 de diciembre de 2022, la solicitud del recurrente, mediante la cual requirió, *“Copia de Directiva de planeamiento (directiva de nivel estratégico militar) y planes de operaciones y órdenes de operaciones, referidas en el artículo 4 del D.S. 003-2020-DE y emitidas en el marco del D.S. 143-2022-PCM, considerando incisos 45.7 y 45.8 del D.S. 003-2020-DE”*, fue reencauzada a la entidad.

Mediante el Oficio N° 152-CCFFAA/SG/UAIP, notificado al recurrente el 18 de enero de 2023, el Secretario General de la entidad denegó la solicitud en base a lo señalado en el Memorandum N° 025 EMCFFAA/D-3/DAI de fecha 10 de enero de 2023, mediante el cual el Jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas señaló: *“(…) es información que está exceptuada de ser público, según lo establecido en el artículo 15°.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información Secreta, del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (…)”*.

Con fecha 23 de enero de 2023, el recurrente presentó ante esta instancia su recurso de apelación, señalando que:

¹ Cabe precisar que, si bien no obra copia de la solicitud, puede advertirse que en el OFICIO N° 00648-2022-MINDEF/SG-OAIP, oficio de reencauce procedente del Ministerio de Defensa y dirigido a la entidad, se consigna el petitorio de la misma, el cual coincide con el contenido de la solicitud descrito en el recurso de apelación.

“(…) Al respecto, debe señalarse que solicito la directiva de planeamiento, los planes de operaciones y las órdenes de operaciones, los cuales fueron emitidos por las Fuerzas Armadas para conducir su accionar durante el Estado de Emergencia a nivel nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 143-2022-PCM. Conforme se advierte del artículo 1 de este decreto supremo, la participación de las Fuerzas Armadas consistió en brindar apoyo en el mantenimiento del orden interno, a cargo de la Policía Nacional del Perú, ante los conflictos sociales registrados a partir del 7 de diciembre de 2022.

Al respecto, el numeral 4.2. del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, refiere que una modalidad de intervención de las Fuerzas Armadas es la que está dirigida a brindar, en el marco de un Estado de Emergencia, apoyo a la Policía Nacional del Perú en el restablecimiento del orden interno ante situaciones de violencia distintas al escenario de un enfrentamiento armado con grupos hostiles.

El artículo 16 del citado decreto legislativo refiere, respecto a esta modalidad de intervención de las Fuerzas Armadas, que “Los principios rectores que rigen antes, durante y después del uso de la fuerza son los reconocidos por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (...)”. En ese sentido, dicho artículo recalca que el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas se sujeta a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Respecto al accionar de las Fuerzas Armadas en la modalidad de intervención antes citada, el numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1095, aprobado por Decreto Supremo N°003-2020-DE, identifica una serie de instrumentos que guían el uso de la fuerza por parte del personal militar². El literal a) de dicho numeral sostiene que “(...) El JCCFFAA [Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas] emite la correspondiente directiva de planeamiento (directiva de nivel estratégico militar), la misma que es aprobada por la Autoridad Superior”. Agrega el literal b) de dicho numeral que el comandante de nivel operacional formula un plan de operaciones, el cual debe ser aprobado por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Añade el literal c) del mismo numeral que “Los comandantes de componente y comandantes de nivel táctico emiten planes de operaciones y órdenes de operaciones, según corresponda, los cuales son remitidos a su comando superior, para su aprobación”.

Como se advierte, en virtud del numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095, las Fuerzas Armadas emiten una directiva de planeamiento, planes de operaciones y órdenes de operaciones, cuando intervienen para brindar apoyo al control del orden interno, a cargo de la Policía Nacional del Perú, en una zona declarada Estado de Emergencia. En tanto el Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, que declaró el Estado de Emergencia a nivel nacional, dispuso la participación de las Fuerzas Armadas para brindar apoyo en el restablecimiento del orden interno, se advierte que dicha entidad ha formulado estos instrumentos sobre uso de la fuerza.

Cabe indicar que el acceso a esta documentación contribuye a que la ciudadanía supervise que los instrumentos que determinaron el accionar militar de las Fuerzas Armadas en el Estado de Emergencia antes citado hayan sido formulados de manera respetuosa de los derechos humanos, y hayan enmarcado el uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

(...)

Por consiguiente, la entrega de la información solicitada permite que la ciudadanía supervise que los instrumentos que rigieron el accionar militar de las Fuerzas Armadas en el Estado de Emergencia previsto en el Decreto Supremo N°143-2022-PCM hayan sido conformes a los parámetros que guían el uso de la fuerza.

² En adelante, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095.

Por otro lado, en relación con el régimen de información secreta, previsto en el artículo 15 del TUO de la Ley de Transparencia, invocado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, debe advertirse que esta entidad no ha demostrado que se cumplen con las condiciones para limitar válidamente el derecho de acceso a la información pública, siguiendo los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

(...)

Si bien el artículo 15 del TUO de la Ley de Transparencia persigue la protección de fines constitucionalmente legítimos como la seguridad nacional o el orden interno, la entidad no ha acreditado o demostrado de qué manera la entrega de la información solicitada amenaza y vulnera la seguridad de las personas, la integridad territorial, la subsistencia del sistema democrático o las actividades de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). No ha precisado de qué manera la difusión de la información solicitada entorpece el apoyo que brinda las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú en el control de los actos de violencia y vandalismo contra instituciones públicas y privadas y de los actos de agresión contra la integridad de ciudadanos y autoridades, que fueron alegados por el Poder Ejecutivo para declarar el Estado de Emergencia mediante el Decreto Supremo N° 143-2022-PCM.

La entidad no ha demostrado dicha amenaza o vulneración a los fines legítimos protegidos por el régimen de información secreta, pese a que tiene la obligación de hacerlo, de conformidad con el Fundamento Jurídico 10 de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N°05173-2011-HD/TC:

(...)

En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido en el principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas” (subrayado añadido).

Se observa que la entidad no cumplió con sustentar que la entrega de la información solicitada pueda suponer una amenaza o riesgo inminente a la defensa nacional u orden interno, por lo que el Principio de Publicidad respecto a la documentación requerida se mantiene vigente.

Asimismo, la entidad ha referido que la información solicitada se encuentra clasificada como secreta. Al respecto, el artículo 15 del TUO de la Ley de Transparencia dispone que la información secreta debe estar previamente clasificada para poder ser denegada. El artículo 21 del Reglamento de dicho cuerpo normativo³ indica que las entidades públicas que posean u obtengan dicho tipo de información deben contar con un registro de la misma. Estos aspectos de la clasificación de la información solicitada no han sido demostrados por la entidad, pese a que tiene la obligación de demostrarlo. Al respecto, resulta pertinente la Resolución del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública recaída en el Expediente N°02601-2021-JUS/TTAIP, en la que desestimó la aplicación de una excepción de información secreta debido a que la entidad no acreditó la clasificación de la información solicitada como secreta.

Cabe agregar que, conforme al artículo 18 in fine del TUO de la Ley de Transparencia, “(...) no se considerará como información clasificada la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las

³ Aprobado por Decreto Supremo N°072-2003-PCM.

excepciones señaladas en este artículo pueden ser utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución Política del Perú” (subrayado añadido)⁴.

(...)

Al respecto, la información solicitada está relacionada a violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas durante su intervención en el Estado de Emergencia a nivel nacional declarado mediante Decreto Supremo N°143-2022-PCM, por lo que resulta aplicable el artículo 18 in fine del TUO de la Ley de Transparencia.

Sobre el particular, cabe mencionar que, con el propósito de observar la situación de derechos humanos en el marco de la crisis institucional y de las protestas realizadas desde el 7 de diciembre de 2022, la CIDH realizó una visita preparatoria al Perú del 20 al 22 de diciembre de dicho año, así como una visita de trabajo al país del 11 al 13 de enero de 2023.

La CIDH ha hecho referencia a violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas en la conferencia de prensa sobre su visita de trabajo: “(...) Desde el inicio de las protestas sociales hasta el día de ayer [12 de enero], se han registrado 47 personas fallecidas, entre ellas, 7 adolescentes. Adicionalmente, han resultado heridos al menos 650 personas y 290 integrantes de las fuerzas de seguridad. Estos hechos han ocurrido principalmente en Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, Junín, La Libertad, Puno y Juliaca, ciudades ubicadas [sobre todo] en la parte sur del país con una población mayoritariamente autoidentificada como indígenas y campesinos” (subrayado añadido)⁵.

La CIDH ha indicado que existen denuncias sobre el uso arbitrario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en el contexto de estas manifestaciones: “En Ayacucho, en las manifestaciones sucedidas el 15 de diciembre, habrían fallecido al menos 12 personas. Según la información recibida, se denuncia que agentes del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza, al momento de repeler un intento de toma del aeropuerto. En dicha acción, también resultaron al menos 70 personas heridas, lo que ocasionó el colapso del sistema de salud local. (...) En Juliaca, se registraron hechos de extrema violencia. Según datos oficiales, como resultado de los enfrentamientos ocurridos el 9 de enero, entre las fuerzas de seguridad y las personas que intentaron tomar el aeropuerto, hasta el momento el recuento total en Juliaca ha sido de 19 personas que perdieron la vida. Según las necropsias, dichas personas fallecieron por heridas de arma de fuego” (subrayado añadido)⁶.

⁴ En particular, las ejecuciones extrajudiciales de personas cometidas por el Estado son consideradas graves violaciones a los derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 41 de la Sentencia de Fondo dictada en el caso Barrios Altos vs. Perú de fecha 14 de marzo de 2001, refirió que: “Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (subrayado añadido)..

⁵ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Conferencia de prensa sobre visita de observación a Perú [videograbación]. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=XojuleVcw8k>. En la misma línea, la CIDH ha referido en un comunicado de prensa sobre la situación de derechos humanos en el Perú que “(...) condena enérgicamente todo acto de violencia e insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para que los hechos de violencia que han resultado en graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigados de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a las personas responsables. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. La CIDH condena el incremento de violencia en el Perú y programa visitas técnicas y de trabajo. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/280.asp>.

⁶ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Conferencia de prensa sobre visita de observación a Perú [videograbación]. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=XojuleVcw8k>. Acerca de los hechos de violencia acontecidos en Juliaca el 9 de enero de 2023, la Defensoría del Pueblo ha manifestado que “Lamentamos las afectaciones al derecho a la vida e integridad de las personas, entre ellas menores de edad, acontecidas como resultado de los enfrentamientos ocurridos el día de hoy en los exteriores del Aeropuerto Inca Manco Cápac de dicha ciudad. (...) El Ministerio Público en su calidad de titular de la acción penal debe realizar las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de la pérdida de vidas humanas, afectaciones a la integridad personal y atentados contra la propiedad, a fin de evitar toda forma de impunidad”. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Pronunciamiento sobre hechos acontecidos en Juliaca. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://www.defensoria.gob.pe/pronunciamiento-sobre-hechos-acontecidos-en-juliaca/>. Sobre los hechos de violencia

*La CIDH ha reiterado su preocupación por las denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad: "En atención a lo observado, la Comisión resalta las denuncias sobre los impactos del despliegue estatal en niñas, niños y adolescentes. En el Perú, existe un marco normativo que regula el uso de la fuerza por agentes del Estado, así como protocolos reportados por el Estado en cumplimiento de recomendaciones de la Comisión (...). En la contención de determinados hechos de violencia, la Comisión recibió denuncias de disparos indiscriminados en contra de personas manifestantes en ciertas regiones como Ayacucho, así como otras denuncias sobre disparos dirigidos a puntos vitales con armas letales y de alto calibre, en violación al principio del uso gradual de la fuerza. El esclarecimiento de estas denuncias es algo a lo que las investigaciones que se realicen deben darle la máxima prioridad, y esclarecer así lo ocurrido" (subrayado añadido)*⁷.

(...)

Conforme se advierte de las declaraciones de la CIDH sobre su visita de trabajo al Perú para observar la situación de los derechos humanos, existen denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad (Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú) en el contexto de las protestas iniciadas el 7 de diciembre de 2022, que requieren ser investigadas por Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos.

*Cabe agregar que la Fiscalía de la Nación del Perú ha dispuesto el inicio de una investigación preliminar contra la Presidenta de la República, Dina Boluarte; el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el Ministro del Interior, Víctor Rojas; el Ministro de Defensa, Jorge Chávez; el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; y el exministro del Interior, César Cervantes, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidas durante las protestas en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en los departamentos de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho*⁸.

*Por su parte, diversos medios de comunicación han reportado sobre el uso arbitrario de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en el contexto de las protestas ciudadanas antes referidas*⁹. Al respecto, Ojo Público ha indicado en un reportaje queda cuenta de los hechos de violencia al 15 de enero de 2023 que "Una serie de imágenes, testimonios, manuales policiales y necropsias analizadas por OjoPúblico exponen graves vulneraciones a los derechos humanos durante las acciones de represión de la policía y militares, principalmente

ocurridos en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022, la Defensoría del Pueblo ha sostenido que "(...) hemos señalado que se habría hecho uso de la fuerza de manera desproporcionada. Corresponde al Ministerio Público proseguir con las investigaciones que ya ha iniciado, debiendo actuar con la máxima diligencia en el marco de sus competencias". DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la protección de derechos ante crisis que afecta al país. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-reafirma-su-compromiso-con-la-proteccion-de-derechos-ante-crisis-que-afecta-al-pais/>. Respecto a las violaciones de derechos humanos registradas al 16 de diciembre de 2022, Amnistía Internacional ha señalado que advierte que "(...) la forma en que las fuerzas militares y policiales han intervenido en la situación va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos y puede agudizar la actual crisis. Desde la declaratoria del estado emergencia a nivel nacional, el 15 de diciembre, Amnistía Internacional ha continuado recibiendo numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales en las protestas sociales, que van desde el uso excesivo de la fuerza y privaciones de la libertad sin respetar el debido proceso, hasta la tortura". AMNISTÍA INTERNACIONAL. Perú: Demandamos el cese inmediato de la violencia estatal y se establezcan responsabilidades por las violaciones de derechos humanos. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://amnistia.org.pe/noticia/cese-violencia-protestas/>.

⁷ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Conferencia de prensa sobre visita de observación a Perú [videograbación]. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=XojuleVcw8k>.

⁸ MINISTERIO PÚBLICO [@FiscaliaPeru]. Comunica el inicio de investigación preliminar contra altas autoridades por presuntos delitos cometidos durante las protestas en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023. Visto: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://twitter.com/FiscaliaPeru/status/1612956655846846464>.

⁹ LA REPÚBLICA. Ayacucho: Las diez víctimas murieron por arma de fuego. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://larepublica.pe/politica/actualidad/2022/12/22/protestas-ayacucho-las-diez-victimas-murieron-por-arma-de-fuego-jhonatan-alarcon-galindo-pnp-ejercito-cidh-congreso-dina-boluarte/>; SALUD CON LUPA. Los muertos de un país fracturado. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://saludconlupa.com/noticias/los-muertos-de-un-pais-fracturado/>; NEW YORK TIMES. Una pausa en las protestas de Perú para honrar a los muertos. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://www.nytimes.com/es/2022/12/19/espanol/protestas-peru-muertos.html>.

en las regiones del sur del país. (...) En 39 días de gobierno, [al 15 de enero de 2023] 49 personas han fallecido en las protestas: 41 civiles y un policía durante las manifestaciones y otras siete a consecuencia del bloqueo de vías y accidentes de tránsito a raíz de la paralización. Entre los fallecidos hay siete menores de edad, tres de ellos eran escolares. Gran parte de las muertes son producto de graves heridas en la cabeza y tórax generadas por proyectiles de armas de fuego de uso policial o militar. El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público reportó que solo en Juliaca –la región con mayor número de muertes– nueve de los 17 fallecidos presentaban proyectiles disparados con armas de fuego. OjoPúblico ha documentado que incluso algunas de estas personas no participaban en las protestas, regresaban a casa o integraban brigadas de ayuda, e igual fueron alcanzadas por los disparos. En este mismo periodo, más de 650 civiles y 250 agentes de las fuerzas del orden han sido heridos. (...) La mayor cantidad de muertes se produjeron en torno a la represión de las fuerzas del orden, cuando los manifestantes intentaron tomar los aeropuertos en Apurímac, Ayacucho y Puno. El 12 y 15 de diciembre del 2022 y, luego, el lunes 9 de enero de este año, grupos de manifestantes ingresaron o intentaron llegar a los aeropuertos de Andahuaylas, Huamanga y Juliaca, respectivamente. Las fuerzas del orden –entre policías y militares– respondieron con violencia: gran parte de ellas por disparos de proyectiles de armas de fuego en la cabeza y el tórax. Así lo confirman las necropsias de varias de las víctimas a la que OjoPúblico tuvo acceso. ‘Herida penetrante en tórax posterior por proyectil de arma de fuego’, ‘herida penetrante en cabeza por proyectil de arma de fuego’, se lee” (subrayado añadido)¹⁰.

Agrega Ojo Público que “Las pruebas sobre el uso de armas de fuego contra civiles por parte de los militares desde el inicio de la represión son distintas y numerosas, pero no se han detenido a pesar del llamado de la Defensoría del Pueblo. Las necropsias realizadas a ocho de los diez jóvenes que fallecieron en Ayacucho señalan que recibieron impactos por proyectiles de arma de fuego. En seis casos, estos impactos fueron en el tórax. En uno, fue en el cráneo y, en otro, en el abdomen. Incluso, hay casos como los del joven cusqueño y el estudiante de gastronomía Rosalino Flores Valverde, de 21 años, que recibió más de 30 proyectiles de armas de fuego (perdigones) en su cuerpo. Los médicos del Hospital Antonio Lorena informaron a OjoPúblico que tiene muy afectados sus intestinos, riñón y pulmón. Su estado es muy crítico. (...) Como OjoPúblico ha explicado en un informe anterior, las acciones policiales para prevenir los disturbios en protestas están enmarcadas en el decreto legislativo 1186 (aprobado en agosto del 2015), que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. La policía no debe disparar a corta distancia de los manifestantes y, cuando lo haga, no debe hacerlo hacia la parte superior del cuerpo, sino hacia la zona inferior. Sin embargo, hay varios heridos críticos por disparos de perdigones a muy corta distancia”.

Añade Ojo Público que “Las imágenes de las protestas desde el 7 de diciembre hasta el momento –recogidas por la Red Investigativa Regional de OjoPúblico y por decenas de ciudadanos– muestran que la policía dispara bombas lacrimógenas y perdigones contra el cuerpo de los manifestantes. También muestran cómo los militares dispararon sus armas de guerra de largo alcance durante la represión, incluso cuando los manifestantes ya huían del lugar. (...) Aunque las investigaciones penales aún están en curso, lo que se ha podido saber es que gran cantidad de personas murieron a causa de los impactos por proyectil de arma de fuego. Todos por heridas provocadas en la parte superior del cuerpo: cabeza y tórax. (...) En las protestas se registraron, además del uso de perdigones

¹⁰ OJO PÚBLICO. Emergencia en Perú: la represión del gobierno de Boluarte expone violaciones a los derechos humanos. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://ojo-publico.com/4201/represion-peru-expone-graves-vulneraciones-los-derechos-humanos>; OJO PÚBLICO. Un memorial por los adolescentes y jóvenes muertos en las protestas. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://ojo-publico.com/4045/un-memorial-los-adolescentes-y-jovenes-muertos-las-protestas>.

y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, disparos de fusiles AKM y galil. Estas últimas armas fueron empleadas por personal del Ejército en Ayacucho, donde también se evidenció que personal de la institución castrense dirigió los disparos directamente hacia el cuerpo de los manifestantes. La presencia de las Fuerzas Armadas se dio después de que el Ejecutivo decretara el estado de emergencia, primero, en ciertas regiones y, luego, lo extendiera a todo el país. La resolución, publicada en el diario El Peruano, autorizó que la PNP, con ayuda de las FF.AA., se haga cargo del control interno.

(...)

En ese sentido, obtener la directiva de planeamiento, los planes de operaciones y las órdenes de operaciones emitidos por las Fuerzas Armadas, emitidos en virtud del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095, en el marco del Estado de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, contribuye a que las personas conozcan las circunstancias en que las Fuerzas Armadas utilizaron la fuerza pública, lo cual repercute en la satisfacción del derecho a la verdad, es decir, en que la sociedad conozca la actuación de las Fuerzas Armadas en lo concerniente a las violaciones de derechos humanos que se perpetraron durante dichas protestas. Asimismo, la entrega de dicha información permite el control ciudadano y la rendición de cuentas. Considerar lo contrario supondría generar espacios de secreto en el corazón del poder público favorables a la impunidad y a prácticas en defensa de intereses de grupo o individuales reñidos con el bienestar general.

Por lo expuesto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas debe proporcionar la información requerida en mi solicitud, al encontrarse amparada dentro del derecho de acceso a la información pública, y al no haberse desvirtuado el principio de publicidad respecto de dicha información, siendo que, al estar referida al accionar de las Fuerzas Armadas durante el Estado de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo N°143-2022-PCM, su entrega contribuye al ejercicio del derecho a la verdad. Además, no corresponde la aplicación del régimen de información secreta, al estar la documentación solicitada relacionada a violaciones a derechos humanos (...)."

Mediante la Resolución N° 000258-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA¹¹, se admitió a trámite el referido recurso impugnatorio y se requirió a la entidad la remisión del expediente administrativo generado para la atención de la solicitud del recurrente, así como la formulación de sus descargos.

Frente a ello, con fecha 31 de enero de 2023, la entidad remitió a esta instancia el Oficio N° 501-CCFFAA/SG/UAIP, a través del cual remitió el expediente administrativo correspondiente y sus descargos contenidos en el Memorandum N° 025 EMCFFAA/D-3/DAI de fecha 10 de enero de 2023, emitido por el Jefe de la División de Operaciones Frente Interno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Informe Ampliatorio N° 001-2023/JCCFFAA/D-3/DAI de fecha 31 de enero de 2023, emitido por el Jefe de la citada División.

Mediante el Memorandum N° 025 EMCFFAA/D-3/DAI de fecha 10 de enero de 2023, el Jefe de la División de Operaciones Frente Interno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, reiteró la respuesta originalmente brindada al ciudadano y agregó que "3.- En cuanto a los Reglas de Conducta Operativa, podrá acceder a través del siguiente link: <https://www.gob.pe/institucion/mindef/normas-legales/2732200-0065-2022-de>".

¹¹ Notificada a la entidad el 27 de enero de 2023.

Mediante el Informe Ampliatorio N° 001-2023/JCCFFAA/D-3/DAI de fecha 31 de enero de 2023, emitido por el Jefe de la citada División, señaló lo siguiente:

“(…)

- 3.- (...), se debe referir que dentro de la documentación que el indicado ciudadano petitionó se encuentra información que no posee carácter de información pública, en aplicación debida e irrestricta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley 27806.
- 4.- Lo anteriormente referido se encuentra taxativamente expuesto en el numeral 45.7 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095; Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, que a la letra establece: "Los pedidos de información o documentación sobre una operación y acción militar son atendidos por la entidad correspondiente de acuerdo a la normativa vigente sobre transparencia y acceso a la información pública."
- 5.- Resulta innegable que el derecho de acceso a la información pública es un derecho que consagra la Constitución Política del Perú: sin embargo, la propia Constitución Política establece las informaciones que afectan la Intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional (conforme al numeral 5 del artículo 2 de la norma constitucional).
- 6.- En ese sentido, el derecho de acceso a la información pública ha sido desarrollado a través, actualmente, del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado con D.S. 021-2019-JUS, normativa que entre otros señala las situaciones de excepciones al derecho de acceso a información.
- 7.- Es así, que **existe la autorización legal para que parte de la información que posean las Entidades del Estado, en este caso el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sea considerada dentro de las excepciones previstas en la normativa aplicable**, por lo que en lo relacionado a la petición denegada que es materia de apelación, se ha dado estricto cumplimiento a lo que establece la Constitución y las Leyes.
- 8.- Como se indicó en su oportunidad, la información requerida por el peticionante tiene la condición de clasificada dentro de las excepciones de ley, dado que se establecen en ellas, la Directiva de nivel estratégico militar. así como de nivel operacional y fáctico, cuyo objetivo es el lograr el restablecimiento y mantenimiento del orden interno, en acciones militares en apoyo al misionamiento constitucional de la Policía Nacional del Perú, dentro del marco de un Estado de Emergencia que a la fecha continua en algunos lugares del territorio nacional.
- 9.- Resulta lógico y necesario entonces que, **en salvaguarda del éxito de las acciones en apoyo a la misión constitucional de mantener y restablecer el orden interno de nuestra gloriosa Policía Nacional, estas disposiciones y planes mantengan un carácter y condición de clasificadas y reservadas**, como para hacerse de conocimiento público per se.
- 10.- Este carácter de clasificados de los documentos y disposiciones, como es de conocimiento público, no es absoluto, ni va en contra de la capacidad fiscalizadora que posee la ciudadanía, sino que dicha capacidad se encuentra focalizado o dirigida por ciertas autoridades a quienes, de ser requeridas, se da acceso a la misma, por lo que estamos ante una situación en la que no se

encuentra autorizada la entrega de la información requerida a parte de la población.

- 11.- Se entiende ello, en el sentido que la difusión de dichos planes y estrategias, implicaría el posible y previsible hecho que no pudieran tener éxito las acciones que el Estado despliega para el mantenimiento del Estado de Derecho y restablecimiento del orden y la paz social a nivel del orden interno. que como es sabido viene siendo violentado por un grupo de personas, que una vez identificados, serán denunciados y procesados por el daño que vienen ocasionando al propio Estado, a las personas y a los bienes.
- 12.- En este caso, **la eficacia y eficiencia de las acciones devienen de su buena ejecución y carácter de reservado, en la obtención del objetivo deseado, siendo que su difusión y entrega significa un riesgo latente en contrario.**
- 13.- Es pertinente, resaltar que dichos planes y directiva se basan en estricto y exactamente en las normativas nacionales del caso, que claramente conoce el peticionante y sus abogados, que a su vez tiene sustento en normas y estándares internacionales que regulan el empleo y uso de la fuerza, a los cuales se da el debido y estricto cumplimiento.
- 14.- En cuanto a la supuesta falta de precisión de la excepción de la información solicitada, basta la lectura del artículo 15 del TUO de la ley 27806 (se pone en **negrita la que corresponde**), que a la letra establece:

"Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la DINI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo:

d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones en Transparencia y Acceso a la Información Pública: Normativa y Jurisprudencia apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.

(...)

No existe duda alguna, que lo peticionado resulta ser visible y notoriamente relacionado a lo que establece la excepción descrita.

- 15.- Lo señalado en el párrafo anterior también se encuentra regulado y previsto en la **Directiva General 01 MINDEF/SG/G Normas para garantizar la seguridad de las informaciones en el Ministerio de Defensa**, la cual dentro de su anexo "I", sobre clasificación y categorización de la documentación relacionadas a la información secreta según el literal d) del artículo 15 de la ley de la materia, dispone:

01: Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, así como operaciones de apoyo a la Policía Nacional del Perú.

04: Publicaciones no orgánicas y Directivas relacionadas a los asuntos de este inciso.

- 16.- Del mismo modo, **Directiva General 022-21/JCCFFAA/SJ Directiva para normar los procedimientos para el acceso, clasificación, archivo y conservación de la documentación en el Comando Conjunto de las fuerzas Armadas**, la cual dentro de su anexo "I", sobre clasificación y categorización de la documentación relacionadas a la información secreta según el literal d) del artículo 15 de la ley de la materia, dispone:
- 01: Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, así como operaciones de apoyo a la Policía Nacional del Perú.**
- 04: Publicaciones no orgánicas y Directivas relacionadas a los asuntos de este inciso.**
- 17.- No puede suponerse menos afirmarse, como temerariamente expresa el peticionante, que la directiva y planes contienen disposiciones relacionadas a violación de Derechos Humanos, cuando es todo lo contrario.
- 18.- Cabe agregar, que deben ser rechazadas tajantemente las aseveraciones sobre que los lamentables fallecimientos acaecidos durante los actos de movilización social en diferentes partes del territorio nacional, que en algunos casos han devenido en actos vandálicos y de otros de connotación delictiva, pues dichas lamentables y sensibles pérdidas, vienen siendo investigadas por la autoridad competente conforme es de conocimiento público y que cita el propio peticionante.
- 19.- Estas afirmaciones, no solo son dañosas para la imagen institucional de las Fuerzas Armadas, sino que también van en contra de la presunción de inocencia que gozan todos los ciudadanos de la Nación, dentro de las que se incluyen las fuerzas del orden. citar publicaciones de medios de comunicación no prueban de modo alguno tales aseveraciones y afirmaciones, lo cual deberá ser evaluado por las instancias correspondientes para las acciones administrativas o legales que pudieran corresponder y puestas en conocimiento del Procurador Público del Ministerio de Defensa, a fin de que en razón de sus competencias evalúe el inicio de las acciones legales correspondientes.
- 20.- Finalmente, debe mencionarse que por todo lo expuesto, **no corresponde la entrega de la información petitionada al estar debidamente justificada y sustentado las condiciones por las cuales se encuentra adecuada a la Constitución y las leyes el carácter clasificado de la Información**" (sic).

Finalmente, el recurrente mediante escrito de fecha 2 de febrero de 2023 solicitó a esta instancia el uso de la palabra.

II. ANÁLISIS

El numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido, con excepción de aquellas informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

En este marco, el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS¹², establece que toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones de ley, teniendo las entidades la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad.

¹² En adelante, Ley de Transparencia.

A su vez, el artículo 10 del mismo texto dispone que las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.

Cabe anotar que el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Transparencia, establece que la denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser fundamentada por las excepciones de ley, agregando el primer párrafo del artículo 18 de la referida norma que las excepciones establecidas en los artículos 15, 16 y 17 del mismo texto son los únicos supuestos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretadas de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental.

Por su parte, el literal d) del numeral 1 del artículo 15 de la referida ley, establece que el derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la DINI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo:
d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.

En ese contexto, el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Transparencia, aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM¹³, señala que cuando se denegara el acceso a la información requerida por considerar que no tiene carácter público, las entidades de la Administración Pública deberán hacerlo obligatoriamente en base a razones de hecho y a las excepciones contempladas en la Ley de Transparencia.

En esa línea, el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia señala que las entidades que produzcan o posean información de acceso restringido llevarán un registro de la misma, el cual se dividirá en información secreta e información reservada. Asimismo, que en el registro deberán consignar los siguientes datos: *a. El número de resolución del titular del sector o del pliego, según corresponda, y la fecha de la resolución por la cual se le otorgo dicho carácter; b. El número de la resolución la fecha de expedición y la vigencia del mandato cuando el titular del sector o pliego, según corresponda, hubiese designado un funcionario de la entidad para realizar la labor de clasificación de la información restringida; c. El nombre o la denominación asignada, así como el código que se le da a la información con el objeto de proteger su contenido, el mismo que deberá estar reproducido en el documento protegido, con el objeto del cotejo respectivo para el momento que se produzca la correspondiente desclasificación; d. La fecha y la resolución por la cual el titular del sector o pliego, según corresponda, prorrogó el carácter secreto de la información, por considerar que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o la subsistencia del régimen democrático, cuando ello corresponda; e. El número, tipo de documento y la fecha con que se fundamentó ante el Consejo de*

¹³ En adelante, Reglamento de la Ley de Transparencia.

Ministros el mantenimiento del carácter restringido de la información, cuando ello corresponda; y, f. La fecha y la resolución de desclasificación de la información de carácter reservado en el caso que hubiera desaparecido la causa que motivó su clasificación, cuando ello corresponda.

Finalmente, el artículo 18 de la Ley de Transparencia establece que las excepciones señaladas en los puntos 15 y 16 incluyen los documentos que se generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona.

2.1. Materia en discusión

De autos se advierte que la controversia radica en determinar si la información solicitada por el recurrente se encuentra inmersa en la excepción al derecho de acceso a la información pública contenida en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

2.2. Evaluación

Sobre el pedido de uso de la palabra

Con relación a la solicitud de uso de la palabra presentada por el recurrente, debe tenerse en consideración lo señalado por el Tribunal Constitucional en el Fundamento 18 de la sentencia recaída en el Expediente N° 01147-2012-PA/TC, en cuanto precisó que no constituye una vulneración del derecho a la defensa cuando en los procedimientos eminentemente escritos no haya sido posible la realización de un informe oral, conforme el siguiente texto:

“18. Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente. Por lo que este extremo de la demanda debe ser desestimado en aplicación, a contrario sensu, del artículo 2º del Código Procesal Constitucional” (subrayado agregado).

En tal sentido, advirtiéndose que el recurrente ha presentado sus argumentos por escrito junto con su recurso de apelación, al no afectarse el derecho al debido procedimiento y dentro del marco del Principio de Celeridad contemplado en el numeral 1.9 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS¹⁴, corresponde desestimar el pedido de uso de la palabra.

¹⁴ En adelante, Ley N° 27444.

Sobre el recurso de apelación

Sobre el particular, toda documentación que obra en el archivo o dominio estatal es de carácter público para conocimiento de la ciudadanía por ser de interés general, conforme lo ha subrayado el Tribunal Constitucional en el Fundamento 5 de la sentencia recaída en el Expediente N° 4865-2013-PHD/TC indicando:

“La protección del derecho fundamental de acceso a la información pública no solo es de interés para el titular del derecho, sino también para el propio Estado y para la colectividad en general. Por ello, los pedidos de información pública no deben entenderse vinculados únicamente al interés de cada persona requirente, sino valorados además como manifestación del principio de transparencia en la actividad pública. Este principio de transparencia es, de modo enunciativo, garantía de no arbitrariedad, de actuación lícita y eficiente por parte del Estado, y sirve como mecanismo idóneo de control en manos de los ciudadanos.”

Al respecto, el artículo 3 de la Ley de Transparencia, que consagra expresamente el Principio de Publicidad, establece que: “Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por (...) la presente Ley”. Es decir, establece como regla general la publicidad de la información en poder de las entidades públicas, mientras que el secreto es la excepción. En esa línea, el Tribunal Constitucional en el Fundamento 8 de la sentencia recaída en el Expediente N° 02814-2008-PHD/TC, ha señalado respecto del mencionado Principio de Publicidad lo siguiente:

“(...) Esta responsabilidad de los funcionarios viene aparejada entonces con el principio de publicidad, en virtud del cual toda la información producida por el Estado es, prima facie, pública. Tal principio a su vez implica o exige necesariamente la posibilidad de acceder efectivamente a la documentación del Estado”.

Teniendo en cuenta ello, el Tribunal Constitucional precisó que le corresponde a las entidades acreditar la necesidad de mantener en reserva la información que haya sido solicitada por el ciudadano, conforme se advierte del último párrafo del Fundamento 13 de la sentencia recaída en el Expediente N° 2579-2003-HD/TC:

“Como antes se ha mencionado, esta presunción de inconstitucionalidad se traduce en exigir del Estado y sus órganos la obligación de probar que existe un bien, principio o valor constitucionalmente relevante que justifique que se mantenga en reserva, secreto o confidencialidad la información pública solicitada y, a su vez, que sólo si se mantiene tal reserva se puede servir efectivamente al interés constitucional que la justifica. De manera que, si el Estado no justifica la existencia del apremiante interés público para negar el acceso a la información, la presunción que recae sobre la norma o acto debe efectivizarse y, en esa medida, confirmarse su inconstitucionalidad; pero también significa que la carga de la prueba acerca de la necesidad de mantener en reserva el acceso a la información ha de estar, exclusivamente, en manos del Estado” (subrayado agregado).

En ese sentido, de las normas legales y los pronunciamientos efectuados por el Tribunal Constitucional antes citados, se infiere que toda información que posean las entidades de la Administración Pública es de acceso público; y, en caso dicha información corresponda a un supuesto de excepción previsto en los artículos 15 a 17 de la Ley de Transparencia, constituye deber de las entidades acreditar dicha condición, debido a que poseen la carga de la prueba.

En el caso de autos, el recurrente solicitó a la entidad *“Copia de Directiva de planeamiento (directiva de nivel estratégico militar) y planes de operaciones y órdenes de operaciones, referidas en el artículo 4 del D.S. 003-2020-DE y emitidas en el marco del D.S. 143-2022-PCM, considerando incisos 45.7 y 45.8 del D.S. 003-2020-DE”*.

Por su parte, la entidad denegó la solicitud en base a lo señalado en el Memorandum N° 025 EMCFFAA/D-3/DAI, mediante el cual el Jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, señaló que la información requerida se encuentra exceptuada de ser entregada en mérito a lo señalado en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

Frente a ello, el recurrente interpuso su recurso de apelación señalando que la información requerida fue emitida por la entidad *“(…) para conducir su accionar durante el Estado de Emergencia a nivel nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 143-2022-PCM. Conforme se advierte del artículo 1 de este decreto supremo, la participación de las Fuerzas Armadas consistió en brindar apoyo en el mantenimiento del orden interno, a cargo de la Policía Nacional del Perú, ante los conflictos sociales registrados a partir del 7 de diciembre de 2022 (…)”*, todo ello en la medida que se encuentra debidamente establecida dicha participación mediante lo establecido en *“(…) el numeral 4.2. del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional (…)”*; y el artículo 16 del aludido decreto, referido a *“Los principios rectores que rigen antes, durante y después del uso de la fuerza son los reconocidos por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (…)”*, haciendo referencia a la sujeción del actuar de las Fuerzas Armadas a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Añade que, conforme al numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE, las Fuerzas Armadas, emiten una directiva de planeamiento, planes de operaciones y órdenes de operaciones, cuando intervienen para brindar apoyo al control del orden interno, a cargo de la Policía Nacional del Perú, en una zona declarada en Estado de Emergencia; por lo que habiéndose declarado dicho estado de excepción a nivel nacional mediante el Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, y habiéndose dispuesto la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo al restablecimiento del orden interno, dichos instrumentos tendrían que haber sido creados.

En ese sentido, el recurrente alega que la información requerida tiene naturaleza pública pues *“(…) contribuye a que la ciudadanía supervise que los instrumentos que determinaron el accionar militar de las Fuerzas Armadas en el Estado de Emergencia antes citado hayan sido formulados de manera respetuosa de los derechos humanos, y hayan enmarcado el uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”*.

Asimismo, señala que, si bien la entidad ha señalado que la información se encuentra protegida por la excepción contenida en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, la entidad *“(…) no ha acreditado o demostrado de qué manera la entrega de la información solicitada amenaza y vulnera la seguridad de las personas, la integridad territorial, la subsistencia del sistema democrático o las actividades de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). No ha precisado de qué manera la difusión de la información solicitada entorpece el apoyo que brinda las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú en el control de los actos de violencia y vandalismo contra instituciones públicas y privadas y de los actos de agresión contra la integridad de ciudadanos y autoridades, que fueron*

alegados por el Poder Ejecutivo para declarar el Estado de Emergencia mediante el Decreto Supremo N° 143-2022-PCM”; es decir, no ha cumplido con demostrar “(...) amenaza o vulneración a los fines legítimos protegidos por el régimen de información secreta (...)”, conforme al Fundamento Jurídico 10 de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N° 05173-2011-HD/TC.

Del mismo modo, el administrado ha aducido que la entidad no ha acreditado que la información se encuentre clasificada como secreta y registrada de dicho modo en el registro pertinente, al amparo de lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia.

Finalmente, enfatiza que la información requerida se encuentra relacionada con *“(...) violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas durante su intervención en el Estado de Emergencia a nivel nacional declarado mediante Decreto Supremo N°143-2022-PCM (...)”,* en el marco de la crisis institucional y de las protestas realizadas desde el 7 de diciembre de 2022 en las que fallecieron 47 personas a nivel nacional en especial en la zona sur del país, bajo el presunto ejercicio desproporcionado de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, citando cifras expuestas por medios de comunicación como Ojo Público y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que resulta aplicable la parte final del artículo 18 de la Ley de Transparencia, referida a que, *“(...) no se considerará como información clasificada la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona (...)”.*

A nivel de descargos, el Jefe de la División de Operaciones Frente Interno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante el Informe Ampliatorio N° 001-2023/JCCFFAA/D-3/DAI, señaló que la información se negó en mérito a que *“(...) Resulta lógico y necesario entonces que, en salvaguarda del éxito de las acciones en apoyo a la misión constitucional de mantener y restablecer el orden interno de nuestra gloriosa Policía Nacional, estas disposiciones y planes mantengan un carácter y condición de clasificadas y reservadas, como para hacerse de conocimiento publico per se”.* En dicha línea, indica que, la clasificación en secreta de la información no contraviene la capacidad fiscalizadora, por el contrario, señala que dicha difusión *“(...) implicaría el posible y previsible hecho que no pudieran tener éxito las acciones que el Estado despliega para el manteniendo del Estado de Derecho y restablecimiento del orden y la paz social a nivel del orden interno. que como es sabido viene siendo violentado por un grupo de personas, que una vez identificados, serán denunciados y procesados por el daño que vienen ocasionando al propio Estado, a las personas y a los bienes”.*

Adicionalmente a ello, señala que la sola lectura del literal “d” del artículo 15 de la Ley de Transparencia devela la naturaleza secreta de la información requerida.

Asimismo, agrega que la clasificación de la información se encuentra regulada mediante la Directiva General 01 MINDEF/SG/G Normas para garantizar la seguridad de las informaciones en el Ministerio de Defensa y la Directiva General 022-21/JCCFFAA/SJ Directiva para normar los procedimientos para el acceso, clasificación, archivo y conservación de la documentación en el Comando Conjunto de las fuerzas Armadas, en *“(...) cuyo anexo “I”, sobre clasificación y categorización de la documentación relacionadas a la información secreta según el literal d) del artículo 15 de la ley de la materia, dispone:*

01: Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, así como operaciones de apoyo a la Policía Nacional del Perú.

04: *Publicaciones no orgánicas y Directivas relacionadas a los asuntos de este inciso". (sic)*

Finalmente, señala que "(...) *no puede suponerse menos afirmarse, como temerariamente expresa el peticionante, que la directiva y planes contienen disposiciones relacionadas a violación de Derechos Humanos, cuando es todo lo contrario*".

Teniendo en cuenta ello, y en tanto la entidad no negó la existencia de la información solicitada, sino que indicó que tiene carácter secreto, corresponde determinar si la entidad atendió el pedido del recurrente conforme a ley.

Sobre la clasificación de la información solicitada como secreta

El artículo 15 de la Ley de Transparencia es el que ha establecido la obligación de clasificar expresamente la información que califica como secreta como requisito para restringir el acceso a dicha información:

"Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la DINI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley".

La obligación de clasificar la información que califica como secreta se cumple a través de la emisión de una resolución del titular de la entidad que le otorga dicho carácter, la cual a su vez se inscribe en un registro creado especialmente para dicho fin. Al respecto, el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia establece lo siguiente:

"Artículo 21.- Registro

Aquellas entidades que produzcan o posean información de acceso restringido llevarán un Registro de la misma, el cual se dividirá en información secreta e información reservada.

En el Registro deberán consignarse los siguientes datos, de acuerdo a su clasificación:

- a. El número de la Resolución del titular del sector o del pliego, según corresponda, y la fecha de la Resolución por la cual se le otorgó dicho carácter;*
- b. El número de la Resolución, la fecha de expedición y la vigencia del mandato cuando el titular del sector o pliego, según corresponda, hubiese designado un funcionario de la Entidad para realizar la labor de clasificación de la información restringida;*
- c. El nombre o la denominación asignada, así como el código que se da a la información con el objeto de proteger su contenido, el mismo que deberá estar reproducido en el documento protegido, con el objeto del cotejo respectivo para el momento en que se produzca la correspondiente desclasificación; (...) "*(subrayado agregado).

La resolución que clasifica la información no constituye un acto discrecional del titular de la entidad o del funcionario delegado por éste, sino que la misma debe

dictarse con base en los supuestos de excepción establecidos en la Ley de Transparencia, y cumplir con el deber de motivar adecuadamente las razones por las cuales la información califica en alguno de dichos supuestos. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en el Fundamento 33 de la sentencia del Pleno Jurisdiccional recaída en el Expediente N° 00005-2013-PI/TC, en el cual ha precisado que la clasificación de la información no solo debe ser nominal, sino que debe estar adecuadamente motivada en los supuestos de excepción establecidos en la Ley de Transparencia:

“Como ya se ha explicado antes y así se desprende del respectivo mandato constitucional y legal, la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es la publicidad de la información financiada por el presupuesto público, de modo que la Administración tiene la obligación de hacer pública tal información. Las excepciones son aquellas expresa y únicamente contenidas en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, e incluso dichas excepciones se aplican de modo restrictivo y sólo cuando la Administración ha justificado o motivado su clasificación como secreta, reservada o confidencial. Si no se ha justificado debidamente la respectiva clasificación carece de efectos la sola nominación formal (colocación de sellos con las expresiones "secreto" o "reservado"), debiendo en todo caso ser la última instancia administrativa en materia de transparencia y acceso a la información pública la encargada de examinar si la información calificada de secreta o reservada reviste realmente o no tal carácter” (subrayado agregado).

De las normas y la jurisprudencia citadas se desprende que cuando una entidad alega que determinada información no puede entregarse por encontrarse clasificada como secreta o reservada, la misma se encuentra en la obligación de acreditar la existencia de la resolución que clasifica expresamente dicha información como secreta, así como de comunicar el sustento con base en el cual se considera que la información solicitada se encuadra en alguno de los supuestos de excepción previstos en los artículos 15 o 16 de la Ley de Transparencia, no bastando para ello la alusión genérica a dichos preceptos normativos, sino que es necesario que se especifiquen las razones por las cuales la documentación solicitada cumple con los distintos elementos que componen la excepción invocada.

Asimismo, conforme lo dispuesto por el citado artículo 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia, la clasificación de la información como secreta o reservada también debe cumplir con determinados requisitos formales, como su aprobación por el titular del sector o pliego o por un funcionario designado por este para dicho fin, mediante una resolución debidamente motivada, la cual debe registrarse con un número, fecha de emisión, y señalando la denominación del documento clasificado y su código.

En el caso de autos, esta instancia aprecia que si bien la entidad ha alegado que la información se encuentra clasificada como secreta, solo ha referido que la entidad clasifica la información según la *Directiva General 01 MINDEF/SG/G Normas para garantizar la seguridad de las informaciones en el Ministerio de Defensa* y la *Directiva General 022-21/JCCFFAA/SJ Directiva para normar los procedimientos para el acceso, clasificación, archivo y conservación de la documentación en el Comando Conjunto de las fuerzas Armadas*; sin embargo, dichos instrumentos normativos internos simplemente constituyen una guía que regula el procedimiento para la clasificación, mas no corresponde a una resolución que clasifica determinada información.

De este modo, la entidad no ha acreditado con ningún documento la aludida clasificación, pese a que, como ya se señaló, la clasificación de información secreta tiene determinadas formalidades, como que la misma haya sido aprobada mediante una resolución del titular del sector o pliego, o funcionario designado por éste, y que la misma se encuentre consignada en el registro correspondiente, y en el cual se especifique la fecha de la resolución de clasificación, la denominación de la información clasificada y su código, siendo que ninguna de dichas formalidades han sido acreditadas por la entidad en el presente caso.

En consecuencia, la entidad no ha cumplido con el requisito legal de la clasificación de la información como secreta para denegar el acceso a la información solicitada.

Sobre la motivación para calificar la información como secreta

No obstante lo anteriormente señalado, la entidad brindó respuesta al administrado señalando que la información solicitada calificaba como secreta, invocando para ello el artículo 15 de la Ley de Transparencia, pero sin precisar la sub causal específica en la cual encajaban los documentos requeridos, con lo cual infringió su deber de motivar adecuadamente la denegatoria de la información.

Sin embargo, en los descargos presentados a esta instancia la entidad ha aducido que la información solicitada se encontraría inmersa en el literal “d” del numeral 1 del mencionado artículo 15 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, la aludida norma establece que:

“Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la DINI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley. En consecuencia, la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo:

(...)

d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.”.

En dicho contexto, en el Informe Ampliatorio N° 001-2023/JCCFFAA/D-3/DAI, emitido por el Jefe de la División de Operaciones Frente Interno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la entidad ha señalado que “No existe duda alguna, que lo petitionado resulta ser visible y notoriamente relacionado a lo que establece la excepción descrita”, añadiendo que la eventual develación de la información “(...) implicaría el posible y previsible hecho que no pudieran tener éxito las acciones que el Estado despliega para el manteniendo del Estado de Derecho y restablecimiento del orden y la paz social a nivel del orden interno (...)”. Asimismo, ha precisado que “la eficacia y eficiencia de las acciones devienen de su buena ejecución y carácter de reservado, en la obtención del objetivo deseado, siendo que

su difusión y entrega significa un riesgo latente en contrario”, más aun cuando la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional continúa en algunas regiones del país.

Al respecto, como ya se ha establecido en la presente resolución, para la denegatoria de una solicitud de acceso a la información pública la entidad debe brindar una motivación suficiente que precise con claridad que la información requerida encaja en los distintos elementos que componen una excepción. En el caso de autos, dicha motivación suficiente implicaba acreditar dos supuestos que apareja la excepción invocada: a) primero, que la información requerida se refiere a órdenes de operaciones, logísticas y conexas, planes de movilización y operaciones especiales relacionados con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, o de operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú; y b) segundo, que la revelación de dicha información afectaría la seguridad nacional, la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, o perjudicaría las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la DINI.

A este respecto la entidad solo ha dicho, sobre el primer punto, que es notorio que lo solicitado encaja en la excepción señalada, y sobre el segundo punto, que la revelación de la información haría que las acciones que despliega el Estado para el restablecimiento del orden no tuviesen éxito.

Es decir, la entidad ha afirmado que los dos elementos de la excepción se cumplen, pero sin brindar mayor explicación de por qué ello es así. Así, en cuanto al segundo elemento, por ejemplo, la entidad no ha detallado qué aspectos de la directiva de planeamiento, los planes y las órdenes de operaciones, de revelarse, afectaría y de qué modo la eficacia o el éxito de las acciones desplegadas para restablecer el orden interno, más aun cuando los documentos solicitados se refieren a operaciones ya ejecutadas, mas no a operaciones por ejecutarse.

Sobre el particular, es preciso destacar que los documentos solicitados fueron documentos que la entidad debió elaborar en el contexto de la declaratoria del Estado de Emergencia a nivel nacional, establecido por el Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, publicado el 14 de diciembre de 2022, en el cual se señaló:

“(…) Artículo 1.- Declaratoria de Estado de Emergencia

Declarar por el término de treinta (30) días calendario, el Estado de Emergencia a nivel nacional. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

(…)

Artículo 3.- Suspensión de los Estados de Emergencia vigentes a nivel nacional

Durante la vigencia del Estado de Emergencia declarado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, queda suspendida la vigencia de los Estados de Emergencia declarados en distintos departamentos del país, en los cuales la Policía Nacional del Perú se encuentra a cargo del control del orden interno.

Artículo 4.- De la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el

territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE, respectivamente”.

Es decir, mediante el aludido decreto supremo se autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas, en apoyo de la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno, disponiendo que su actuación se regulaba por el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional¹⁵, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE¹⁶.

En dicho contexto, el numeral 4.2. del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095, es el que prevé los documentos a ser elaborados por las Fuerzas Armadas para su intervención en apoyo de la Policía Nacional del Perú:

“Artículo 4.- Precisiones respecto del accionar de las FFAA

- 4.1 En aquellas zonas declaradas en Estado de Emergencia, en las que el control del orden interno se encuentre a cargo de las FFAA, las operaciones y acciones militares son planeadas, conducidas, ejecutadas y supervisadas por un comando de nivel operacional con la participación de la PNP, la que previa coordinación cumple las disposiciones de dicho comando de acuerdo con lo establecido en la norma específica.*
- 4.2 En todos los casos en los que se disponga la participación de las FFAA, ya sea operaciones militares o acciones militares:*
 - a. El JCCFFAA emite la correspondiente directiva de planeamiento (directiva de nivel estratégico militar), la misma que es aprobada por la Autoridad Superior.*
 - b. En el caso de que las FFAA asuman el control del orden interno en una zona declarada en Estado de Emergencia, el comandante de nivel operacional emite un plan de campaña; en los demás escenarios, formula un plan de operaciones. En todos los casos, estos planes deben ser aprobados por el JCCFFAA.*
 - c. Los comandantes de componente y comandantes de nivel táctico emiten planes de operaciones y órdenes de operaciones, según corresponda, los cuales son remitidos a su comando superior, para su aprobación” (subrayado agregado).*

Es decir, conforme a esta normativa, cuando las Fuerzas Armadas brindan apoyo a la Policía Nacional en zonas declaradas en Estado de Emergencia, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emite la directiva de planeamiento, el comandante de nivel operacional emite un plan de operaciones, el comandante de componente emite también un plan de operaciones y el comandante de nivel táctico emite las correspondientes órdenes de operaciones.

Ahora bien, es necesario resaltar en este punto que las directivas, planes y órdenes que involucren el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para el restablecimiento del orden interno en el contexto de un Estado de Emergencia, deben formularse en respeto del marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así lo ha establecido el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1095, el cual expresamente prescribe:

¹⁵ En adelante, Decreto Legislativo N° 1095.

¹⁶ En adelante, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095.

“5.2 Cuando la actuación de las Fuerzas Armadas en Estado de Emergencia se orienta a realizar acciones militares en apoyo a la Policía Nacional para el control del orden interno, rigen las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

En dicha línea, el artículo 16 del aludido decreto legislativo establece que los principios rectores que rigen antes, durante y después del uso de la fuerza son los reconocidos por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: son los de legalidad, necesidad y proporcionalidad¹⁷.

Asimismo, el artículo 18 de la referida norma ha previsto que la fuerza debe ser utilizada de modo progresivo según las circunstancias del caso concreto, esto es en el marco de niveles de uso de la fuerza como son el nivel preventivo (involucra la presencia militar, el contacto visual y la verbalización) y posteriormente y previa advertencia cuando se han agotado las acciones preventivas, el nivel reactivo (que involucra el control físico, el uso de medios no letales y uso de medios letales)¹⁸.

Del mismo modo, la norma en cuestión en su artículo 19 también ha previsto las circunstancias excepcionales en las cuales pueden utilizarse armas de fuego, destacando que su uso solo puede justificarse en la protección de la vida o la integridad física del propio personal militar o de alguna otra persona, y ello por cuanto la posibilidad de afectar la vida e integridad física con el empleo de un arma de fuego solo puede estar justificado en la salvaguarda de un bien jurídico de la misma importancia¹⁹.

¹⁷ “a. **Legalidad.**- El uso de fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas debe estar amparado en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento.

b. **Necesidad.**- El análisis de la necesidad en cuanto al uso de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas implica dos verificaciones: (i) haber agotado el despliegue de medidas que no implican el uso de la fuerza y que permitiesen alcanzar el resultado esperado; y, (ii) luego de esta verificación, llegar a la conclusión de que un eventual uso de la fuerza resulta inevitable para alcanzar dicho resultado.

c. **Proporcionalidad.**- Es la equivalencia o correspondencia entre la gravedad de la amenaza y el grado de fuerza empleada, debiendo ser ésta la mínima necesaria en relación a dicha amenaza y en función al resultado legal esperado”.

¹⁸ “**Artículo 18.- Niveles de uso de la fuerza**

18.1.Preventivo

a. **Presencia Militar.**- Es la demostración de autoridad, en la que los miembros de las Fuerzas Armadas están uniformados, equipados, en actitud diligente y de alerta, actuando preventiva y disuasivamente a fin de mantener o restablecer el orden interno.

b. **Contacto Visual.**- Es el dominio visual sobre una persona, grupo de personas, vehículos, áreas o instalaciones, que permite ejercer un cierto control sobre la situación.

c. **Verbalización.**- Es el uso de la comunicación oral, utilizando el tono y los términos necesarios que sean fácilmente comprendidos, con miras a mantener o restablecer el orden interno.

18.2 Reactivo

Agotadas las acciones del nivel preventivo y antes de usar la fuerza en el nivel reactivo, se realiza la advertencia correspondiente, procediendo al uso de la fuerza gradualmente, siempre y cuando la situación lo permita, de la manera siguiente:

a. **Control físico.**- Es la acción militar que utiliza técnicas de fuerza corporal, con el fin de controlar, reducir, inmovilizar o conducir ante la autoridad que corresponda a quienes se encuentren alterando el orden interno.

b. **Medios no letales.**- Se refiere al empleo de equipamiento y armas con bajo potencial de daño, para contrarrestar o superar la amenaza existente.

c. **Medios letales.**- Excepcionalmente, se puede proceder al empleo de armas de fuego, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 19 del presente Decreto Legislativo”.

¹⁹ “**Artículo 19.- Uso excepcional**

19.1 Excepcionalmente, los miembros de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de la misión asignada pueden usar armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.

19.2 Si como consecuencia del uso de las armas de fuego se produjeran heridos, los miembros de las Fuerzas Armadas habilitan la atención médica inmediata, sin discriminación. En caso de que se registren personas fallecidas se adoptan los protocolos correspondientes para el tratamiento de los restos humanos. En ambos casos, se procede a informar a los familiares”.

En dicho escenario es que los documentos sobre planes y órdenes de operaciones que impliquen el uso de la fuerza deben establecer claramente las responsabilidades, las medidas a adoptarse y las reglas sobre el uso de la fuerza en la operación a realizarse, conforme lo detalla el numeral 28.3 del artículo 28 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095:

“28.3 Los planes y ordenes de operaciones referidos al uso de la fuerza, deben:

- a. Establecer claramente la línea de mando, relaciones de comando y las responsabilidades específicas de los comandantes involucrados, en cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 3, incisos 2 al 6.*
- b. Estar sustentados, fundamentalmente, en la misión asignada, la apreciación de inteligencia y en la logística disponible.*
- c. Detallar las medidas a adoptar en caso haya afectaciones a la vida e integridad de las personas, comprendiendo las obligaciones referentes a las facilidades que se deben de brindar a personal humanitario y de salud.*
- d. Especificar las Reglas de uso de la Fuerza (RUF) implementadas al comandante militar responsable de la acción militar, así como aquellas retenidas por los niveles superiores.*
- e. Contener un anexo legal que incluya la evaluación jurídica escrita del AJO respecto de las acciones militares, la cual es obligatoria en los niveles estratégico militar y operacional. En el nivel táctico, el comandante militar debe requerir la opinión jurídica respectiva:*
 - i) Cuando le sea ordenado explícitamente por su superior inmediato.*
 - ii) Aun sin haber recibido una orden al respecto, siempre que considere que ello sea necesario para el cumplimiento de su misión”.*

Es decir, la intervención de las Fuerzas Armadas en el contexto del restablecimiento del orden interno no conlleva una actuación discrecional, sino que la misma se encuentra claramente reglada, en salvaguarda de evitar sacrificios innecesarios de la vida o la integridad física que puedan producirse como consecuencia del uso de la fuerza que ejecute el personal militar. Tal es la finalidad de someter el uso de la fuerza al Derecho y de tutelar con ello la vida de las personas, que las normas aquí citadas incluso han previsto la rendición de cuentas por parte del personal militar cuando se efectúe en el seno de una operación militar el empleo de la fuerza letal. Así lo ha dispuesto el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 1095:

“Artículo 20.- Informe sobre el uso de armas de fuego

20.1 Los miembros de las Fuerzas Armadas que hagan uso de armas de fuego presentan en el término de la distancia un informe por escrito a su superior, dando cuenta de los siguientes aspectos: fecha, hora y lugar del incidente, unidad o elemento que participó en el incidente, hechos que condujeron a su participación, la causa por la cual se abrió fuego, el tipo y la cantidad de armas y municiones empleadas, daños personales o materiales causados, número de eventuales detenidos, heridos o muertos, debiendo acompañar, en lo posible, registros fílmicos o fotográficos existentes.

20.2 Si como consecuencia del uso de las armas de fuego se produjeran daños personales o materiales, el superior o la autoridad competente proceden a la indagación correspondiente, a fin de establecer las circunstancias de la acción”.

En el mismo sentido, el artículo 31 de la misma norma establece que el comandante a cargo de la operación debe presentar un informe de las incidencias ocurridas durante la operación ejecutada:

“Artículo 31.- Presentación de informe

Concluidas las operaciones o acciones previstas en el presente Decreto Legislativo, el comandante de la fuerza militar presenta un informe por escrito a su superior, dando cuenta de los siguientes aspectos: fecha, hora y lugar de las operaciones o acciones, unidad o elemento participante, hechos que condujeron a su participación, las operaciones o acciones efectuadas, sus resultados y otros aspectos de relevancia”.

Finalmente, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095 en los numerales 45.7 y 45.8 ha previsto incluso la posibilidad de acceder a información sobre operaciones militares en las cuales se haya hecho uso de la fuerza, a través de un procedimiento de acceso a la información pública:

“Artículo 45.- Procedimientos como consecuencia del empleo o uso de la fuerza

(...)

45.7 Los pedidos de información o documentación sobre una operación o acción militar son atendidos por la entidad correspondiente de acuerdo a la normativa vigente sobre transparencia y acceso a la información pública.

45.8 Toda persona tiene derecho a recibir información completa, veraz y oportuna sobre las personas heridas o fallecidas como consecuencia de una operación o acción militar, así como sobre las personas que hayan sido intervenidas (...) (subrayado agregado).

Esta norma no califica pues la información sobre una operación militar ejecutada en la cual se haya hecho uso de la fuerza como secreta, sino que deriva el tratamiento de los pedidos de información sobre dicha materia a la Ley de Transparencia, lo que conlleva a presumir el carácter público de dicha información, y a restringir su acceso solo en determinados supuestos tasados en las excepciones, y bajo una interpretación restrictiva de las mismas.

En dicha línea, es preciso tener en cuenta que el artículo 10 de la Ley de Transparencia establece que constituye información pública toda aquella que sustenta una decisión administrativa financiada por presupuesto público. Es decir, típicamente los documentos en los cuales se plasman los actos de la autoridad pública y aquellos que se utilizaron para la adopción de dichas decisiones constituyen información de acceso público.

En dicho sentido, es pertinente destacar que el Tribunal Constitucional en el Fundamento 8 de la sentencia recaída en el Expediente N° 02814-2008-PHD ha establecido que una de las funciones esenciales del acceso a la información pública es la posibilidad de fiscalizar el ejercicio de la función pública por parte de funcionarios y servidores públicos:

“Uno de los elementos esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho es la responsabilidad de los funcionarios. Ello implica una capacidad fiscalizadora importante por parte de la población a fin de controlar a los funcionarios y servidores públicos, idea central o nuclear del sistema democrático. Esta responsabilidad de los funcionarios viene aparejada entonces con el principio de publicidad, en virtud del cual toda la información producida por el Estado es, prima facie, pública. Tal principio a su vez implica o exige necesariamente la posibilidad de acceder efectivamente a la documentación del Estado. Como ya se dijo en la STC 04912-2008-HD/TC, el tener acceso a los datos relativos al manejo de “la res pública resulta esencial para que exista una opinión pública verdaderamente libre que pueda fiscalizar

adecuadamente la conducta de los gobernantes” (fundamento 3)” (subrayado agregado).

En el caso de autos, los documentos relativos a las operaciones militares (directivas de planeamiento, planes y órdenes militares) son documentos que contienen el planeamiento respecto a la actuación de las fuerzas militares en determinada circunstancia, incluyendo –como ya se señaló- las líneas de responsabilidad, las medidas a adoptarse y las reglas sobre el uso de la fuerza. Dicho planeamiento constituye pues un acto de autoridad pública que –como ya se vio- se encuentra estrictamente reglado y sujeto por la normativa citada a una serie de procedimientos de rendición de cuentas respecto a la ejecución de las acciones militares, en especial de aquellas en las cuales se hizo uso de la fuerza y de las armas, y en las cuales fallecieron personas.

Por esta razón, dicha información en la medida que permite escrutar que el ejercicio de la función pública –que incluye la actuación del personal militar- se realizó conforme a ley es información de naturaleza pública, que solo puede quedar restringida con base en un supuesto de excepción específico y siempre que se acredite que su divulgación puede afectar el bien jurídico protegido por dicha excepción, y que la protección de dicho bien resulta más importante que el acceso a la información pública en el caso concreto (principio de proporcionalidad).

En el caso de autos, sin embargo, la entidad no ha cumplido su obligación de motivar adecuadamente que nos encontremos en un supuesto de información secreta, pues si bien los documentos solicitados se encuentran descritos en el literal d) del numeral 1 del artículo 15 de la Ley de Transparencia, no ha justificado cómo la revelación de dichos documentos puede afectar la seguridad nacional, la seguridad personal, la integridad territorial o la subsistencia del sistema democrático, tratándose de documentos relativos a operaciones policiales ya ejecutadas.

La entidad en su respuesta al pedido de información no brindó al administrado ninguna justificación adecuada de la denegatoria, pues solo citó el artículo 15 de la Ley de Transparencia, y tampoco ha subsanado dicha omisión brindando a esta instancia una motivación suficiente de dicha denegatoria, por lo que la presunción de publicidad sobre la información requerida se mantiene.

Adicionalmente a ello, es preciso destacar que el derecho de acceso a la información pública no solo permite el escrutinio del ejercicio de la función pública, sino que sirve también para el ejercicio de otros derechos fundamentales. En ambos campos su ejercicio resulta trascendente. Por ello su limitación no solo debe basarse en la invocación de una excepción, sino que es preciso que se justifique, en base al principio de proporcionalidad, que la divulgación de información afecta el bien jurídico protegido por la excepción y que la protección de dicha información resulta más importante que el acceso a la misma en las circunstancias del caso concreto.

Respecto a lo señalado por el recurrente, cabe agregar que en el supuesto que se estableciera que la información solicitada estuviera relacionada con graves violaciones a los derechos humanos, la Ley de Transparencia le otorga a la misma una protección máxima en cuanto a su publicidad, pues el último párrafo de su artículo 18 ha previsto que no se considera como secreta o reservada:

“Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 16 incluyen los documentos que se generen sobre estas materias y no se considerará como información

clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las excepciones señaladas en este artículo pueden ser utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución Política del Perú”.

Lo que supone que en caso existiera una vinculación entre la información requerida y el conocimiento de las circunstancias, causas y responsables de hechos que califican como graves violaciones a los derechos humanos, la mencionada información goza de un marco de máxima publicidad.

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el Expediente 2488-2022-HC/TC, el derecho a conocer la verdad de lo sucedido en casos de graves violaciones a los derechos humanos no solo constituye un derecho de las víctimas de dichas violaciones, sino que dicho derecho a la verdad cuenta también con una dimensión colectiva, en virtud a la cual la sociedad en conjunto “(...) tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como los motivos que impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico colectivo inalienable”.

Bajo este marco explicativo, para este Tribunal resulta claro que la prohibición de clasificar como secreta o reservada la información relacionada a graves violaciones a derechos humanos tiene su fundamento en el derecho a la verdad. Si en caso se estableciera que existen daños graves a la dignidad humana, que socavan el modelo mismo de Estado Constitucional y Democrático de Derecho, el conocimiento de la información sobre dichas violaciones a los derechos humanos sería de interés general. La máxima publicidad de dicha información garantizaría, además, la vigilancia sobre las investigaciones adelantadas por los Estados para la determinación de responsabilidades por dichos hechos.

Siendo esto así, conforme al artículo 18 de la Ley de Transparencia, en el supuesto que la información solicitada (en el presente caso, Directiva de planeamiento (directiva de nivel estratégico militar) y planes de operaciones y órdenes de operaciones, emitidas en el marco del D.S. 143-2022-PCM) se encontrara relacionada a la vulneración de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949, realizada por cualquier persona, en cualquier circunstancia, la misma no sería considerada como reservada, secreta o confidencial.

En consecuencia, corresponde estimar el recurso de apelación y ordenar a la entidad que entregue la información pública solicitada por el recurrente.

Finalmente, de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Transparencia, aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, en aplicación de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, corresponde a cada entidad determinar la responsabilidad en que eventualmente hubieran incurrido sus funcionarios y/o servidores por la comisión de presuntas conductas infractoras a las normas de transparencia y acceso a la información pública.

Asimismo, el artículo 4 de la Ley de Transparencia, señala que todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente norma y que los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta Ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso

denunciados penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que hace referencia el artículo 376 del Código Penal.

Además, el artículo 368 del Código Penal establece que el que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

Por los considerandos expuestos y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 y en el numeral 1 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses; asimismo, ante la abstención formulada por la Vocal Titular Silvia Vanesa Vera Munte declarada fundada²⁰ anteriormente y el orden de prelación establecido en la Resolución N° 031200212020 de fecha 13 de febrero de 2020, interviene la Vocal Titular de la Primera Sala María Rosa Mena Mena.

SE RESUELVE:

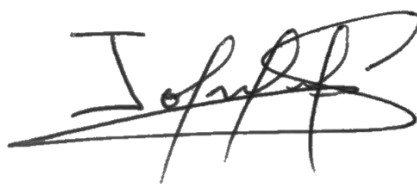
Artículo 1.- DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación presentado por **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA** contra la respuesta contenida en el Oficio N°152-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023; y, en consecuencia, **ORDENAR al COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS** que entregue la documentación solicitada, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución, bajo apercibimiento de que la Secretaría Técnica de esta instancia, de acuerdo a sus competencias, remita copia de los actuados al Ministerio Público en caso se reporte su incumplimiento, en atención a lo dispuesto por los artículos 368 y 376 del Código Penal.

Artículo 2.- SOLICITAR al **COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS** que, en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, acredite a esta instancia la entrega de dicha información al recurrente **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA**.

Artículo 3.- DECLARAR agotada la vía administrativa al amparo de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley N° 27444.

Artículo 4.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la notificación de la presente resolución a **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA** y al **COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS**, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la norma antes citada.

Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional (www.minjus.gob.pe).



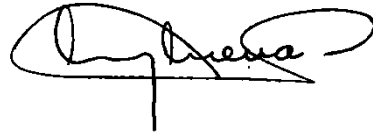
JOHAN LEÓN FLORIÁN
Vocal Presidente

²⁰ Conforme a lo resuelto en la Resolución N° 2323-2021-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA de fecha 8 de noviembre de 2021.

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop at the top and a horizontal line at the bottom.

VANESSA LUYO CRUZADO
Vocal

vp: fjlf/idcg

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop at the top and a horizontal line at the bottom.

MARIA ROSA MENA MENA
Vocal